

1500109-49.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... é conhecido dos meios policiais pelo tráfico e não aparentava estar sob efeito de drogas.

Este depoimento foi confirmado pelo policial Tarcísio, que ainda detalhou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, avistou quando o Réu recebia dinheiro do ocupante do aludido Gol e, em seguida, foi até aquele terreno, se abaixou em uma pilha de tijolos, onde, posteriormente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500109-49.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500109-49.2022.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Périkilson Arantes Biscassi

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. PÉRIKLISON ARANTES BISCASSI, qualificado nos autos a fls. 18, foi denunciado e

viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 23.08.2006, porque no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 20h, na Rua 6 nº 1.532, Bairro Bom Jesus, nesta cidade e Comarca de Guaíra, uma porção de maconha, com peso líquido de 10,08 g, duas porções do mesmo entorpecente, com peso líquido de 46,73 g, além de sete microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 2,38 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que “na data dos fatos policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado, pessoa conhecida nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, recebendo uma cédula de dinheiro do condutor de um veículo que estava parado no meio da rua. Ato contínuo, PÉRIKLISON foi até uma pilha de tijolos localizada em uma casa abandonada.

Os policiais, então, se aproximaram e o abordaram, enquanto o condutor do veículo evadiu-se do local.

Realizada busca pessoal, foram apreendidos em poder do denunciado um canivete e uma porção de maconha. Em seguida, os policiais localizaram mais 7 pinos de cocaína e duas porções de maconha naquela pilha de tijolos, motivo por que ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia.”.

A denúncia de fls. 109/110 foi recebida em 12 de abril de 2022 (fls. 113). O Réu foi citado a fls. 126, apresentando defesa preliminar em fls. 131/136, rejeitada a fls. 138. Na instrução da foi colhida prova oral e, ao final, o Réu foi interrogado (cf. fls. 174 e 186).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia (fls. 184/185).

A douta Defesa, por seu turno, a fls. 188/190, requereu a absolvição do Acusado por ausência de prova e, subsidiariamente, desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. De outro modo, sustenta que, caso condenado, deveria ocorrer a redução da pena com base no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, bem como fixação de regime diverso do fechado e substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

Ao término da instrução processual e após uma atenta análise dos autos, é de se afirmar que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está evidenciada no auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/06, boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, auto de constatação preliminar de fls. 14/16, documento de fs. 22/23, guia de depósito judicial de fls. 97, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 120/122, bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria é certa contra o Réu que em Juízo negou o teor da denúncia, dizendo que na data dos fatos estava com dois amigos na 6 com a 33 fumando maconha quando avistaram duas viaturas, de forma que se desfez do cigarro de maconha, recebendo todos ordens para que sentassem. Nada de ilícito com eles foi localizado, passando, então, os policiais a procurar algo, entrando naquela casa e voltando com uma sacola, dando-lhe voz de prisão e liberando seus amigos. Ressalta, ainda, que não havia um Gol vinho naquele momento, desconhece de quem seja aquela droga e trabalha com o pai como servente de pedreiro.

Sua versão não convence e ficou completamente isolada do contexto probatório colhido nestes autos, mormente fazendo ouvir seus dois amigos, que segundo alega, estavam no momento da abordagem, ônus que lhe competia com base no artigo 156 do

Código de Processo Penal.

O policial militar Edinalvo, ouvido em Juízo, afirmou que estavam em patrulhamento quando avistaram o Réu entregando algo ao ocupante de um veículo Gol de cor vinho que, ao perceber a viatura, saiu em disparada, assim como o Réu, que correu para um terreno onde havia uma casa com aspecto abandonada. Foi perseguido e encontrado com ele um canivete, um tablete de maconha e dinheiro, ao passo que no local onde ele estava localizaram, na pilha de tijolos, mais entorpecente. Disse, ainda, que o Réu é conhecido dos meios policiais pelo tráfico e não aparentava estar sob efeito de drogas.

Este depoimento foi confirmado pelo policial Tarcísio, que ainda detalhou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, avistou quando o Réu recebia dinheiro do ocupante do aludido Gol e, em seguida, foi até aquele terreno, se abaixou em uma pilha de tijolos, onde, posteriormente, encontraram o restante do entorpecente, tratando-se de cocaína e outros tabletes de maconha.

A testemunha André deu depoimento que pouco contribuiu em auxiliar o Acusado, uma vez que se limitou a dizer não ter visto o tal veículo de cor vinho ou os policiais entrando no terreno, o que não pode ser levado em muita consideração porque, trabalhando no bar, não é de se acreditar que ele ficasse o tempo todo vendo o que se passasse na rua. Ademais, o fato de que o Réu estivesse com dois amigos – sequer ouvidos, conforme sobredito – pouco acresce à tese defensiva.

A análise das provas indica que o Acusado infringiu o disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Isso se deve porque o Réu trazia consigo e tinha em depósito considerável quantidade de maconha e também cocaína, para os padrões desta cidade, o que, aliado à forma em que estavam acondicionadas, o conhecimento dos policiais de que o Réu pratica a venda de drogas, o local ser conhecido como ponto de venda de drogas, não aparentar o Acusado estar sob efeito de entorpecentes e o dinheiro apreendido sem origem lícita declinada, indicam, sem dúvida, a ocorrência do crime tal como descrito na denúncia. Tais condutas apontam, destarte, que o Réu iria utilizar o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, considerando o quadro posto, certa a procedência da ação penal. Oportuno salientar que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, tanto que não foram contraditados.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das

tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Réu não ostenta antecedentes criminais certificados nos autos que possam ser considerados para exasperação da pena. Contudo, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, uma vez que a considerável quantidade de maconha e de cocaína apreendidas com o Réu, apontando maior perniciosidade de sua conduta, circunstância que revela situação de maior gravidade, de forma que a aumento em 1/6 (um sexto), estipulando sua pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal, à míngua de comprovação das condições financeiras do Acusado. Fixo esta pena no patamar ora lançado, diante da inexistência de outras circunstâncias que pudessem ser consideradas para alterá-la.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que não comprovou ocupação lícita o que, aliado à quantidade e diversidade de droga apreendida, demonstram que o Réu se dedica, exclusivamente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, já que não é de se supor que seria autorizado pelo crime organizado a com eles concorrer em ponto de venda de drogas, indicativo claro que não praticou o crime ao qual ora condenado de forma esporádica, agindo de maneira repentina e incontrolável, mas um verdadeiro meio de trabalho ilícito. Ao revés, segundo depoimento dos policiais, ele era conhecido pelo tráfico e aquele local é notório ponto de venda de drogas. Dessa maneira, torno aquela pena definitiva, ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Nessa linha: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'.

Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.

Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

Importante consignar que caberia à defesa a prova de que o Acusado faria jus à causa de diminuição acima mencionada, considerando-se que esta não é automática e somente de aplicação possível quando presentes os requisitos legais, forte no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, ou seja, "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer". Desta forma, o Réu deveria indicar, através de provas, que não se dedicava à atividades criminosas, afastando o quanto foi comprovado pela acusação, isto é, que estava com considerável quantidade de drogas, em atos de traficância, e não possui emprego lícito.

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado a hediondo, é o inicial fechado. Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência do requisito subjetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Ressalto, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido,

justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012).

E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu, depositados em Juízo (fls. 97), que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º, da Lei 11.343/06).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu PÉRIKLISON ARANTES BISCASSI, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda do dinheiro apreendido com ele, depositado a fls. 97, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como encaminhe-se o numerário apreendido, depositado a fls. 97, em benefício da União.

Tendo em vista que o Réu respondeu em liberdade este processo, assim pode aguardar o julgamento de eventual recurso.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA